

1502929-75.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502929-75.2020.8.26.0536 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502929-75.2020.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2234875 - 03º D.P. SANTOS, 1163/20/010 - 03º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR DOS SANTOS TEIXEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

VÍTOR DOS SANTOS TEIXEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, inciso II (escalada), c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta que no dia 23 de setembro de 2020, por volta de 1h30, na Avenida Mário Covas nº 3050, Ponta da Praia, em Santos, o réu tentou subtrair, para ele, durante o repouso noturno, mediante escalada, cerca de 25 metros de fio de 3,5 mm, avaliados em R\$ 300,00 (trezentos reais), pertencentes ao Grupo Mendes Empreendimentos, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, sendo que no citado local estava sendo construído o Centro de Convenções do Grupo Mendes. Consta também, que na data e local acima citados, durante a madrugada, o acusado se aproximou de bicicleta do local e ingressou no imóvel, após escalar a cerca metálica de cerca de 2 metros de altura instalada na obra. Na sequência, ele se

apoderou do citado fio elétrico, cortando-o do quadro de disjuntores e o acondicionou na caixa plástica instalada em sua bicicleta (cargueiro). O vigilante da obra, durante a ronda ali realizada, avistou o réu no local, tentando arrastar uma placa de alumínio. Ao perceber a aproximação do vigilante, o acusado se evadiu do local, deixando para trás sua bicicleta, não conseguindo consumir a ação delitiva.

Consta, ainda, que o funcionário comunicou os fatos a policiais militares que passavam pelo local, apontado as características do furtador (indivíduo pardo, magro, trajando bermuda escura e camisa camuflada) que, em diligências, conseguiram localizar o acusado na Rua Miguel Xavier de Moraes, próximo à favela denominada Vila Sapo, o qual correspondia às características informadas e tinha em seu poder um alicate e um martelo pequeno, e, questionado pelos policiais, o acusado admitiu informalmente a prática delitiva.

Consta, por fim, que o vigilante da obra procedeu ao reconhecimento do acusado, sendo que, na bicicleta deixada pelo réu no local, dentro da citada caixa plástica, foram localizados os cerca de 25 metros de fio subtraídos.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 05). Boletim de ocorrência (fls. 02/04).

Auto de Exibição/Apreensão (fls. 08). Laudos periciais (fls. 71/73 e 77/82).

A denúncia foi recebida em 15/10/2020 (fls. 90).

O réu foi citado (fls. 129/130) e apresentou resposta à acusação (fls. 148/150).

Durante a instrução foram colhidos os depoimentos do representante da vítima e de três testemunhas comuns, bem como o réu foi interrogado (fls. 204/205).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos termos da denúncia. Disse que a autoria e a materialidade estão plenamente comprovadas. Argumentou que não há dúvidas quanto a ter o acusado praticado o crime que lhe foi imputado. Sustentou que os funcionários da empresa vítima confirmaram a prática do delito, chamando a polícia após a fuga do acusado. Aduziu que o réu confessou a prática do delito, devendo esta ser reconhecida. Disse que também devem ser reconhecidas as circunstâncias descritas na denúncia de escalada e da prática do crime no repouso noturno. Aduziu que, tendo em vista os péssimos antecedentes do acusado, deve ser aplicado o regime semiaberto.

A Defesa, por sua vez, requereu a parcial procedência da ação, devendo ser reconhecida a tentativa. Afirmou que o acusado confessou espontaneamente o delito. Na dosimetria, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, devendo ser reconhecida a atenuante da confissão. Pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução.

A autoria também é certa e atribuída ao acusado.

O representante da vítima, MARCELO DE ALMEIAS, disse que foi chamado, pois houve um furto na obra. Falou que nas obras têm muito fio, cobre e alumínio. Afirmou que a obra é toda fechada com placas de aço. Explicou que lembra vagamente dos fatos e que o acusado estava sozinho no dia dos fatos. Aduziu que o réu foi surpreendido no local, sendo acionada a viatura policial. Falou que não estava no local, sendo chamado para ir até lá, já na madrugada, após a meia noite. Disse que foi chamado pela testemunha Raul. Falou que nem ele e nem Raul conheciam o acusado antes dos fatos.

A testemunha RAUL BEIN PEREIRA disse que estava fazendo ronda na madrugada, quando identificou o réu no local dos fatos. Disse que isso era por volta de 1h30 da madrugada. Falou que foi detectado o furto de fios. Afirmou que o réu entrou no imóvel, mas que não sabe como isso aconteceu. Explicou que o local é todo cercado com placas, que tem por volta de 2 metros de altura. Falou que, após pegar os fios, o réu os colocou no bagageiro de sua bicicleta. Disse que surpreendeu o réu, mas na

fuga ele caiu da bicicleta, a deixando no local, fugindo a pé. Falou que reconheceu réu pelo casaco camuflado que ele vestia. Disse que as placas não estavam avariadas. Falou que viu um indivíduo, de longe, dentro do imóvel, mas que depois ele fugiu. Disse que os fios estavam no bagageiro da bicicleta do acusado, mas que na fuga ficou tudo no local. Aduziu que soube que o réu foi preso por volta de meia hora depois dos fatos. Explicou que a polícia trouxe o acusado ao local dos fatos e ele o reconheceu dentro da viatura. Falou que a altura da placa chegava a mesma de seu o braço levantado, estando em pé. Disse que acha que ele usou a bicicleta como apoio para pular a cerca. Falou que o local estava todo cercado. Disse que nunca viu o réu antes dos fatos.

A testemunha LUIZ ANTONIO DOS SANTOS, policial militar, disse que o acusado entrou no centro de convenções, que ainda estava em obras. Afirmou que os vigias acionaram a polícia militar e que diligenciou pelas redondezas, quando encontrou o acusado escondido, atrás de uma árvore. Falou que quem abordou o réu foi o seu parceiro. Explicou que o réu foi abordado em uma rua atrás do centro de convenção, cerca de 50/60 metros do local dos fatos. Disse que o vigia reconheceu o acusado. Narrou que não conhecia o réu antes dos fatos.

A testemunha BRUNO CARLOS DA SILVA SANTOS, policial militar, disse que vigias da obra informaram sobre um furto no local, quando fizeram patrulhamento pelas redondezas. Afirmou que, ao passar pela Rua Rep. Do Equador, avistou um indivíduo abaixado, atrás de uma árvore, quando efetuou a abordagem do acusado. Falou que o pessoal da obra reconheceu o acusado, mas que não se lembra se ele confessou no momento da abordagem. Disse que o local onde o réu foi preso fica por volta de 1 quadra e meia do local dos fatos. Afirmou que não conhecia o acusado antes dos fatos.

O réu, VÍTOR DOS SANTOS TEIXEIRA, interrogado em Juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia. Disse que estava com dificuldade financeira e que decidiu praticar o furto. Falou que já foi preso e processado anteriormente. Narrou que parou de bicicleta em frente da obra e pulou o muro. Disse que estava com um alicate e desligou a extensão, a pegando. Falou que o vigia escutou o barulho, quando fugiu do local. Explicou que o vigia foi atrás dele e que na fuga abandonou a bicicleta e continuo correndo a pé. Disse que, antes de praticar o crime, tinha saído da cadeia há quase dois anos. Falou que, após ser solto por este crime, foi preso novamente, após 10 dias, por outro delito.

Diante das provas amealhadas aos autos, verifico que o réu praticou o delito de furto qualificado pela escalada, durante o repouso noturno, na forma tentada, fato típico previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, uma vez que tentou subtrair para si bens pertencentes à empresa vítima Grupo Mendes Empreendimentos S/C LTDA.

Os depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas são contundentes elementos de convicção que respaldam a acusação acerca da prática do crime de furto pelo acusado, acrescentando-se, ainda, que este confessou a prática delitiva.

A confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, consiste em elemento securíssimo de convicção. E, na hipótese dos autos, foi corroborada pelos demais elementos de prova colhidos sob o manto do contraditório, restando demonstrado, portanto, que o acusado, mediante escalada e durante o repouso noturno, tentou subtrair bens de uma obra pertencente à empresa vítima, não obtendo êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista que foi surpreendido pelo vigia da obra no momento da subtração.

Desta forma, as testemunhas narraram o ocorrido, de modo que restou clara a prática do delito pelo acusado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

"Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento securíssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica a sua recusa". (JUTACRIM 93/239 - Rel. Juiz Canguçu de Almeida).

"... não se pode perder de vista que, sem razão extraordinária, não é comum alguém mentir contra si próprio. E, na espécie, não se vislumbra fatos que pudessem implicar no reconhecimento de uma falsa confissão, levadas a efeito sob o crivo do

contraditório. A confissão, de mais a mais, merece eficácia probatória porque crível e verossímil, fruto da clara correlação entre os testemunhos, tudo a permitir a responsabilidade penal da recorrente ..." (TJSP, Apelação nº 0035628-85.2011.8.26.0577, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 5.10.2016). A testemunha Raul Bein Pereira, que trabalhava como vigilante no local dos fatos quando o acusado empreendeu na prática criminosa, disse que avistou o réu no interior da obra, mas que ele logrou êxito em fugir, quando acionou a polícia, dizendo, ainda, que logo em seguida, os policiais apresentaram a ele o acusado, o reconhecendo como o autor do delito.

Já as testemunhas policiais disseram em Juízo que foram acionadas para atender uma ocorrência de furto, na obra do centro de convenções e, de posse das características do acusado, passaram a diligenciar pelas cercanias, quando abordaram o acusado em rua atrás do local dos fatos, agachado atrás de uma árvore. O Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu pela eficácia dos depoimentos de policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos probatórios.

Neste sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (...) 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a fração de incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas para 1/6, ficando a reprimenda final em 10 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 1.399 dias-multa, mantido o regime fechado." (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018). Grifei.

Nesse sentido, a res furtiva foi localizada em uma caixa de plástico que estava presa à bicicleta do acusado, de modo a sua apreensão em poder do agente implica inversão do ônus da prova, cabendo à Defesa apresentar justificativa convincente para o ocorrido, o que na espécie não se deu.

Neste sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO LEGÍTIMA. PENABEM DOSADA. 1) Absolvção Impossibilidade. Provas suficientes de materialidade delitiva e autoria. Provas orais suficientes à condenação, robustecidas no caso concreto pela clara recalcitrância do acusado à ação da Justiça, o qual, tendo tido a revelia decretada, deixou sponte própria de exercer a faculdade da auto defesa. Bens subtraídos encontrados na posse do acusado em flagrante realizado pela própria vítima. Inversão do ônus da prova. Em tais casos, compete ao réu demonstrar a legitimidade da posse do bem Precedentes jurisprudenciais. 2) Pena bem dosada. Regime fechado adequado. Maus antecedentes. Reincidência. Impossibilidade de regime de início de cumprimento menos rigoroso, indiferente o quantum da sanção..." (TJSP, Des. Alcides Malossi Júnior, AP nº: 0006340-37.2012.8.26.0196).

De mais a mais, conforme já acima destacado, os depoimentos das testemunhas vão ao encontro da confissão judicial perpetrada pelo réu. Ademais, quando preso em flagrante pelos policiais, logo após a prática criminosa, o réu estava na posse de um alicate e um martelo, objetos estes utilizados para cortar os fios e desses se apoderar, o que corrobora a versão apresentada pelas testemunhas ouvidas em Juízo.

Ainda, ao que se vê da prova pericial, bem como da sólida prova oral, a qualificadora relativa à escalada é situação perfeitamente configurada, pois é de se reconhecer que o réu efetivamente escalou e pulou a cerca metálica existente no local dos fatos para conseguir entrar no local e subtrair os bens pertencentes ao estabelecimento vítima.

A esse propósito, o laudo pericial é claro ao demonstrar que o local é totalmente cercado, com uma cerca metálica de aproximadamente 2 metros de altura, de modo que impossível o acesso do réu ao interior da obra que não seja mediante escalada. Outro ponto a se destacar é o que crime foi praticado durante a madrugada, por volta da 1h30, o que caracteriza ter sido o delito cometido durante o repouso noturno.

Cumprе salientar que, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a hipótese de prática delitiva durante o repouso noturno, embora integre o tipo penal do furto simples, pode ser aplicada ao furto qualificado.

Não há, assim, qualquer incompatibilidade na aplicação da referida causa de aumento nas hipóteses de furto qualificado, uma vez que os parágrafos do art. 155 interferem em momentos distintos da dosimetria da pena.

Após o julgamento do Recurso Especial nº 1.193.194-MG do Superior Tribunal de Justiça, quando foi admitida a aplicação da causa de diminuição do § 2º do art. 155 do Código Penal no furto qualificado, o Superior Tribunal de Justiça passou a não ver impedimento para a incidência da causa de aumento, uma vez que superada a questão da posição topográfica. Neste sentido, no informativo de jurisprudência nº 554, o Superior Tribunal de Justiça fez constar que:

“DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. A causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do CP - que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - é aplicável tanto na forma simples (caput) quanto na forma qualificada (§ 4º) do delito de furto. Isso porque esse entendimento está em consonância, mutatis mutandis, com a posição firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.193.194-MG, no qual se afigurou possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP), máxime se presentes os requisitos. Dessarte, nessa linha de raciocínio, não haveria justificativa plausível para se aplicar o § 2º do art. 155 do CP e deixar de impor o § 1º do referido artigo, que, a propósito, compatibiliza-se com as qualificadoras previstas no § 4º do dispositivo. Ademais, cumpre salientar que o § 1º do art. 155 do CP refere-se à causa de aumento, tendo aplicação apenas na terceira fase da dosimetria, o que não revela qualquer prejuízo na realização da dosimetria da pena com arrimo no método trifásico. Cabe registrar que não se desconhece o entendimento da Quinta Turma do STJ segundo o qual somente será cabível aplicação da mencionada causa de aumento quando o crime for perpetrado na sua forma simples (caput do art. 155). Todavia, o fato é que, após o entendimento exarado em 2011 no julgamento do EREsp 842.425-RS, no qual se evidenciou a possibilidade de aplicação do privilégio (§ 2º) no furto qualificado, não há razoabilidade em negar a incidência da causa de aumento (delito cometido durante o repouso noturno) na mesma situação em que presente a forma qualificada do crime de furto. Em outras palavras, uma vez que não mais se observa a ordem dos parágrafos para a aplicação da causa de diminuição (§ 2º), também não se considera essa ordem para imposição da causa de aumento (§ 1º). (HC 306.450-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 4/12/2014, DJe 17/12/2014.)”. Grifei.

Nesse sentido, também é a jurisprudência do TJSP:

“FURTO QUALIFICADO TENTADO. Rompimento de obstáculo. Repouso noturno. Prova robusta da autoria e da materialidade, bem como da causa de aumento de pena e da qualificadora. Causa de aumento prevista no artigo 155, § 1º, do CP, que, segundo a jurisprudência do STJ, é aplicável tanto ao furto simples, como ao qualificado, e a

estabelecimentos comerciais. Impossibilidade de reconhecimento do "princípio da insignificância" ou do privilégio. Penas que comportam redução. Básicas que partiram dos mínimos legais e foram acrescidas de um terço pela causa de aumento do repouso noturno. Possibilidade de redução pela tentativa na fração máxima, diante do diminuto iter criminis. Réu que foi surpreendido ao arrombar a porta do estabelecimento comercial e que sequer chegou a ter êxito e ingressar no local. Regime aberto adequado. Substituição da pena corporal que deve ser por uma restritiva de direitos, na forma do art. 44, § 2º, do CP. Insuficiência da substituição somente por multa. Custas processuais. Impossibilidade de pagamento que deve ser discutida em sede de execução. Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1500648-88.2016.8.26.0536; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de Registro: 19/03/2018)". Grifei. Por fim, deve ser reconhecido que o acusado praticou o delito na forma tentada, haja vista que foi surpreendido durante a prática criminosa, pois o vigilante que trabalhava no local dos fatos chegou no momento em que ele perpetrava a subtração, quando empreendeu em fuga, deixando os fios no bagageiro de sua bicicleta, no local dos fatos, de modo que não há se falar em consumação da subtração. Assim, a prova colhida traz a certeza necessária para o decreto condenatório, restando comprovada a prática do delito tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, sendo a condenação medida de rigor.

Passo, pois, a dosar a pena.

Na primeira fase, atento-me aos critérios norteadores estampados no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima.

Nesta esteira, observo que o réu ostenta maus-antecedentes, conforme demonstra a certidão de fls. 98/101 e a folha de antecedentes de fls. 102/113. Ressalta-se, ainda, que o réu tem a personalidade voltada à prática criminosa, haja vista que faz do crime um meio de vida. Em razão disto, elevo a pena-base em 1/3, fixando-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente em crime doloso, conforme a certidão de fls. 98/101 e a folha de antecedentes de fls. 102/113. Dessa forma, presente se faz a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Anoto, ainda, que em seu interrogatório, o acusado confessou a prática do delito descrito na denúncia, o que, em tese, impõe a aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", também do Código Penal.

No entanto, a reincidência é preponderante, por força do artigo 67 do Código Penal. Consoante estabelece o referido artigo, no concurso de agravantes e atenuantes, preponderam as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Assim, de acordo com o entendimento tradicional, e ainda majoritário, inclusive adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a reincidência é circunstância subjetiva de maior prevalência, sucumbindo apenas perante a atenuante da menoridade.

Desta forma, vale ressaltar trecho do V. Acórdão proferido recentemente no julgamento do HC 198395 AgR, pelo Ministro Alexandre de Moraes, em 08/04/2021: "Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que, a teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão (RHC 118107, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2014). Precedentes: RHC 135819, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/6/2018; RHC 110727, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/5/2012; HC 105.543, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/5/2014; RHC 120.677, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014; HC 112.830, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012; HC

108.138, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 14/12/2011)".

Segue, assim, ementa do citado Acórdão:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PACIENTE MULTIRREINCENTE. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REAVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 198395 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 12-04-2021 PUBLIC 13-04-2021)".

A respeito, seguem outras decisões do Supremo Tribunal Federal:

"Penal. Dosimetria. Concurso entre atenuante e agravante Art. 67, CP.

Preponderância da reincidência sobre a confissão espontânea. 1. A teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes. 2. Ordem denegada". (HC 96061/MS, Segunda Turma, Relator Ministro Teori Zavascki, DJE 02.04.2013).

"EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, "a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada" (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. (HC 105.543/MS, j. 29/04/2014).".

Neste sentido, também, segue entendimento do C. TJSP:

"APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - AFASTAMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA - RÉU RECALCITRANTE - ESCALADA COMPROVADA POR IDÔNEO LAUDO PERICIAL - PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA À CONFISSÃO - EXEGESE DO ART. 67 DO CP - PRECEDENTE - NECESSIDADE DO REGIME FECHADO - RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E PROVIDO APELO MINISTERIAL. (TJSP; Apelação Criminal 0000100-57.2015.8.26.0574; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/09/2016; Data de Registro: 29/09/2016)". Grifei.

Logo, sendo a reincidência circunstância preponderante em relação à atenuante da confissão, inviável a compensação entre elas, e, portanto, aumento em 1/6 a pena fixada, somando-a em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, em razão de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno, aumento a pena de 1/3 (um terço), resultando em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Restou configurada, também, a modalidade tentada, de modo que se faz presente a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Anoto que, em razão do iter criminis percorrido pelo agente, haja vista que o acusado foi visto ainda no interior da obra pertencente à empresa vítima e, na tentativa, deixou os bens no local, sendo detido a pouco metros, de modo a consumação, embora iniciada, não se findou. Assim, diminuo a reprimenda pela metade, fixando-a por definitivo em 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no mínimo legal, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Mesmo diante da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, deixo de substituí-la por pena restritiva de direitos, pois a reincidência e os maus-antecedentes do acusado indicam que a substituição não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.

Pelos mesmos motivos, também não é viável a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, incisos I e II do Código Penal.

Ainda que considerada a reincidência do acusado, fixo como regime inicial para o cumprimento da pena aplicada o semiaberto, em razão de a pena cominada ser inferior a 04 (quatro) anos, sendo a medida socialmente recomendável à luz da Súmula 269 do

STJ.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, o que faço para CONDENAR o acusado, VÍTOR DOS SANTOS TEIXEIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

O réu poderá recorrer em liberdade, haja vista que respondeu grande parte do feito nesta condição, devendo-se observar que encontra-se preso por outro Juízo.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa.

Arbitre os honorários do defensor nomeado no valor máximo da tabela vigente, expeça-se o necessário.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais em razão de ter sido assistido por advogado dativo.

Por fim, deixo de fixar a indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, haja vista que o réu não levou qualquer bem do ofendido, não tendo sido, ainda, o prejuízo comprovado pela vítima.

P.I.C.

Santos, 21 de fevereiro de 2022.

Leonardo de Mello Gonçalves

Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA